



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד**

מס' תיק: 12/41/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

לפני כבוד המפקח על רישום מקרקעין אלעד אזר

התובעות	1	נציגות בניין ברח' ירושלים 14 ו-16 אשדוד
	2	מ.ז. שמדר ניהול פרויקטים בע"מ, חברה 514709617
		באמצעות ב"כ: עו"ד נחום הרפז ואחרים יד חרוצים 19, ירושלים
	נגד	
הנתבעת	1	שוש נחמיאס חברה לבניין בע"מ, חברה 511916025
		באמצעות ב"כ: עו"ד יצחק סרויא ו/או דורון מור שד ירושלים 18, אשדוד

פסק דין חלקי

פסק דין זה עניינו במחלוקת שנתגלעה בין הצדדים בגין חיוב הנתבעת בתשלום עבור דמי הניהול והתחזוקה השוטפים לידי חברת הניהול והתחזוקה של הבית המשותף ובתשלום דמי "גביה מיוחדים" לידי נציגות הבית המשותף. הנתבעת היא אשר בנתה את הבית המשותף מושא התביעה ובתקופה הרלוונטית החזיקה ועודנה מחזיקה עד היום במספר לא מבוטל של דירות בבית המשותף.

רקע עובדתי

1. עסקינן בבית המשותף הידוע כגוש 2072 חלקה 49 וממוקם ברח' ירושלים 16 ו-18 באשדוד. הבית המשותף מורכב משני מגדלי מגורים הכוללים 186 דירות וידוע גם כמתחם " K TOWERS". הבית המשותף טרם נרשם בפנקס הבתים המשותפים.
2. הנתבעת היא החברה שיזמה את הקמת הבית המשותף ובנתה אותו. בהתאם להסכמי המכר עם רוכשי הדירות מונתה חברה מטעמה - ש.א. אחזקות בע"מ (המהווה חברת בת של הנתבעת), לשמש כחברת הניהול והתחזוקה של הבית המשותף ובמילים אחרות לשמש כ"מתחזק" של הבית המשותף כמשמעות מונח זה בסעיף 71(ב) לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן: "**חוק המקרקעין**"). לאחר תחילת אכלוס הבית המשותף ובמשך כשנתיים פעלה חברת ש.א. אחזקות כחברת הניהול והתחזוקה של הבית המשותף.
3. התובעת 1 היא נציגות הבית המשותף (להלן: "**הנציגות**"). בהתאם להחלטה שהתקבלה במסגרת אסיפה של בעלי הדירות ביום 26.3.2019 הוחלט על התנתקות מחברת ש.א. אחזקות ולהסמיק את הנציגות להתקשר בחוזה עם התובעת 2 (להלן: "**שמדר**"). ביום 28.7.2019 נחתם בין הנציגות לשמדר הסכם למתן שירותי ניהול ואחזקה עבור הבית המשותף ע"י שמדר וזאת



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 12/41/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לתקופה של 48 חודשים. הלכה למעשה שמדר החלה להעניק את שירותיה לבית המשותף בחודש מאי 2020.

4. במסגרת התביעה שהוגשה נגד הנתבעת, תובעת שמדר מאת הנתבעת תשלום דמי ניהול עבור כל הדירות שהיו בבעלותה במועד תחילת פעילותה בחודש מאי 2020 ועד לחודש יולי 2020 בסך של 154,554 ₪ בצירוף דמי פיגור. כן עתרה לסעד הצהרתי לפיו הנתבעת חייבת לשלם לה את דמי הניהול על כל הדירות שבבעלותה בהתאם להסכם ולכל אורך תקופתו.

5. במסגרת כתב הגנתה העלתה הנתבעת טענה עקרונית ולפיה, בהתאם להסכמי המכר שנחתמו עם כלל הרוכשים, הרי שמלכתחילה ניתן לה פטור בגובה מחצית מתשלום דמי התחזוקה והניהול עבור הדירות שבבעלותה, ומהמועד בו נותרו בבעלותה 60% מהדירות בבית המשותף היא תהנה מפטור מלא מתשלום דמי הניהול והתחזוקה של הרכוש המשותף.

בסעיף 11(ד) לכל הסכמי המכר שנחתמו בין הנתבעת לרוכשי הדירות נקבע כך: **"החל ממועד המסירה מתחייב המוכר לשאת בהוצאות החזקת הרכוש המשותף וכל המתקנים המשותפים בבניין ובפרוייקט, וזאת בחלקו היחסי כמפורט בהסכם, וישלם את חלקו בהוצאות אלה לפי דרישת נציגות הבית המשותף או המוכר או חברת הניהול. בין הצדדים הוסכם במפורש, כי כל עוד לא נמסרו 60% מן הנכסים בבניין, ישלם המוכר לנציגות הבית ו/או חברת הניהול פלי העניין, בגין יחידות שלא נמכרו, 50% מהוצאות ההחזקה כאמור לעיל עד למסירתן. לאחר מסירת 60% מן הנכסים בבניין על ידי המוכר, ישאו רוכשי הזכויות בנכסים לבדם בהוצאות ההחזקה, והמוכר לא יידרש לשלם בגין הנכסים שטרם נמסרו"** (הדגש אינו במקור א.א.).

6. הואיל וכתב ההגנה נמסר לידי התובעות רק יום לפני הדיון הראשון שהתקיים בפני, אפשרתי לתובעות להגיש בקשה לתיקון כתב התביעה. ביום 3.2.21 נעתרתי לבקשת התובעות להגיש כתב תביעה מתוקן תוך חיובן בהוצאות. הוגש כתב תביעה מתוקן ובעקבותיו כתב הגנה מתוקן.

7. בעקבות דיון נוסף נקבע כי הצדדים ישלימו את ההליכים המקדמיים שעניינם פירוט הדירות שהיו בבעלות התובעת בחודש מאי 2020 ולאופן חישוב דמי הניהול לגביהם. וכי הנתבעת תמציא העתק של 10 חוזי מכר באופן אקראי ותצהיר לפיו כל חוזי המכר כוללים את סעיף הפטור שמחלוקת. עוד התבקשו הצדדים להודיע אם הם מבקשים להגיש תחילה טיעונים בכתב בסוגיה המשפטית שעל הפרק.

8. בהחלטתי מיום 12.12.21 קבעתי כי לשם יעילות הדיון יגישו הצדדים סיכומים בכתב בסוגיה המרכזית שעל הפרק, שאינה דורשת שמיעת עדויות ואשר הכרעה בה עשויה לייתר את המשך ההליך, או לפחות לצמצמו במידה רבה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 12/41/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

טענות התובעות

9. כטענה מקדמית טוענות התובעות כי אף אם תתקבל באופן עקרוני טענת הנתבעת לעניין פטור מדמי ניהול ואחזקה הרי שלא יהיה מנוס מלקיים בירור עובדתי בשאלה אלו דירות אכן מכרה הנתבעת עד למועד התביעה שכן בידי התובעות ראיות לכך שלפחות חלק מהדירות שבבעלות התובעות מושכרות על ידה והיא אף גובה בגין דמי ניהול שהיא משלשלת לכיסה.
10. בראש טענות התובעות כנגד תוקפה של תנית הפטור עליה מבקשת להסתמך הנתבעת ניצבת טענתן כי מדובר סעיף המהווה תנאי מקפח בחוזה אחיד עפ"י סעיף 2 לחוק חוזים אחידים, תשמ"ג-1982 (להלן: "החוק" או "חוק החוזים האחידים"). עפ"י טענה זו, חוזי המכר בין הנתבעת לרוכשי הדירות מהווים חוזה אחיד לפי חוק החוזים האחידים ואף הנתבעת למעשה מודה מכך בעצם טענתה כי סעיף בנוסח זהה הפוטר אותה מדמי ניהול נכלל בכל חוזי המכר.
11. העובדה כי ללקוח יכולת להכניס שינויים כאלה ואחרים בחוזה אינה שוללת את היותו של החוזה חוזה אחיד. אין לקבל את הטענה כי בשל כך שלקוח מסוים מני רבים הכניס שינוי באחד מתניותיו של חוזה כדי לשלול מעמדו כחוזה אחיד. אין הלקוח נדרש להוכיח כי לא ניתנה לו אפשרות לשאת ולתת על שינוי תנאים שהוא הראה כי הם אחידים.
12. מההסכמים שנמסרו במסגרת הליך גילוי מסמכים עולה כי אין כל הבדל בין ההסכמים למעט התאמות של ההסכם בכל הקשור למיקום הדירה, גודלה, מחירה וכיוב'.
13. אשר להוכחה כי תנאי בחוזה אחיד מהווה "תנאי מקפח", הרי שסעיף 4 לחוק החוזים האחידים מונה מספר חזקות אשר די בכך שתנאי מסוים נכלל בגדר את מהן כדי ליצור חזקה כי הוא תנאי מקפח. בעניינו תנית הפטור עליה מסתמכת הנתבעת עונה על ההגדרות שבסעיף 4(1) לחוק לאמור: "תנאי הפוטר את הספק, באופן מלא או חלקי, מאחריות שהיתה מוטלת עליו על פי דין אילולא אותו תנאי, או המסייג באופן בלתי סביר את האחריות שהיתה מוטלת עליו מכוח החוזה אילולא אותו תנאי".
14. בניגוד למקרה שנדון בעש"א 50204-10-19, בו ביהמ"ש ציין כי לא היתה התייחסות של הנציגות לשאלה האם חלה חזקה לפי סעיף 4 לחוק לפיה תנית הפטור מהווה תנאי מקפח, הרי שהתובעות העלו טענה זו בכתב התביעה המתוקן ובסיכומיהן.
15. אלמלא תנית הפטור, היה מוטל על הנתבעת לשלם את דמי הניהול בגין הדירות שנשארו בבעלותה ותנאי זה מקפח את רוכשי הדירות הנאלצים לשאת בנטל מוגבר לשם תחזוקת הרכוש המשותף.
16. בנוסף, טוענות הנתבעות כי תנית הפטור מנוגדת להוראות סעיף 30 לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1970 בשל היותו "חוזה שכריתתו, תכנו או מטרותו הם בלתי חוקיים, בלתי מוסריים או סותרים את תקנת הציבור סותר את תקנת הציבור..." ולפיכך דינה להתבטל. סעיף הפטור נוגד את תקנת הציבור שכן רוכשי דירה חדשה בבית משותף נדרשים לתחזק את הרכוש



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 12/41/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

המשותף ללא השתתפות בעל דירה שפטרו עצמם בחוסר תום לב. הסעיף פוטר את הנתבעת מתשלום שהיה מוטל עליה אלמלא הכלל בחוזה המכר.

17. עוד טוענות התובעות כי תנית הפטור עליה נסמכת הנתבעת עומדת בסתירה ברורה ללשונו של סעיף 58 לחוק המקרקעין לפי כל בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף לפי יחס שטח רצפתו אל שטח הרצפה של כל הדירות. זוהי הוראה קוגנטית שלא ניתן להתנות עליה.

טענות הנתבעת

18. עד חודש מאי 2020 מכרה הנתבעת למעלה מ- 70% ממלאי הדירות שבנתה.
19. למפקח על רישום מקרקעין אין סמכות לדון בשאלה האם הסכמי המכר מהווים חוזה אחיד והאם תנאי הפטור מהווה תנאי מקפח בחוזה אחיד.
20. לגופו של החוזה הנדון, הסכמי המכר עם הרוכשים אינם מהווים חוזה אחיד ותנית הפטור אינה תנאי מקפח בחוזה אחיד. תנית הפטור שנכללה במסגרת הסכמי הרכישה עם הקונים היא סעיף מסחרי מקובל בהסכמים מסוג זה. הרוכשים ידעו מלכתחילה על הפטור הצפוי טרם חתימתם והיה עליהם להביא בחשבון את עלות תניה זו במסגרת שיקוליהם הכלכליים. חברי הנציגות עצמם ידעו על תנית הפטור מבעוד מועד וכמו מרבית הרוכשים, היו מיוצגים ע"י עורכי דין וניהלו מו"מ בקשר לסעיפי ההסכם ובהסכמים רבים נערכו שינויים במסגרת נספח שינויים שצורף לכל הסכם. מרביתם של נספחי השינויים חוללו שינוי משמעותי בהסכם המכר המקורי.
21. לתצהיר מטעם יועמ"ש הנתבעת צורפה רשימה ארוכה של דיירים שערכו שינויים ארוכים ומפורטים.
22. ביהמ"ש העליון קבע כי תנאי כמו זה שכללה הנתבעת בהסכמי הרכישה אינו מהווה תנאי מקפח.
23. ניתן להתנות על הוראות סעיף 58 לחוק המקרקעין, כפי שנקבע בעש"א 50204-10-19.
24. אין כל בסיס לטענה כי תנית הפטור נוגדת את תקנת הציבור זהו תנאי מסחרי סביר ומקובל.
25. משעה שנמכרו מעל 60% ממלאי הדירות אין רלבנטיות לשאלה כמה דירות נותרו במועד הגשת התביעה בבעלות הנתבעת.

דיון והכרעה

- תנית פטור בחוזה מכר דירה יכולה לגבור על הוראת סעיף 58 לחוק המקרקעין.
26. נקודת המוצא לדיון בשיעור השתתפות דייר בבית משותף בהוצאות הרכוש המשותף – וזאת, בין שהבית נרשם כבית משותף ובין שטרם נרשם ככזה (לאור הוראות [סעיף 77א' לחוק המקרקעין](#)) – נמצא בהוראות [סעיף 58 לחוק המקרקעין](#) הקובע:



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 12/41/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

"בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחויבים על פי דין או המקובלים על פי הנהוג לפי יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר..." (ההדגשה אינה במקור – א.א.)

קרי, שיעור ההוצאות הוא בהתאם ליחס בין שטח רצפת דירת הדייר לבין שטח רצפת כלל הדירות בבית המשותף, אלא אם נקבע אחרת בתקנון. מתוך הסיפא [לסעיף 58](#) נמצאנו למדים כי הוראת [סעיף 58](#) היא דיספוזיטיבית, קרי ניתנת להתנאה וזאת, במסגרת תקנון הבית המשותף (ראו לעניין זה [עש"א \(מחוזי מרכז\) 23578-07-14](#) אלי רוני ואבי יוזמה ופתוח בע"מ נ' ק.ר. 42 השקעות ונכסים (2000) בע"מ (11.02.2015)).

27. בענייננו ההתנאה על הוראות [סעיף 58 לחוק המקרקעין](#) נקבעה במסגרת הסכמי מכר הדירות אשר נערכו בין הדיירים (הם רוכשי הדירות) לבין הנתבעת. בהוראות הסכמי מכר הדירות בין הדיירים לבין הנתבעת, בכל הנוגע לשינוי שיעור השתתפות בהוצאות הרכוש המשותף, ניתן לראות כהוראות תקנוניות וזאת, לאור הוראת [סעיף 6 לחוק המכר \(דירות\)](#) שכותרתו: "תקנון בבית משותף", אשר קובע:

"(א) המוכר דירה בבית משותף או בבית המיועד להירשם כבית משותף והתקנון שחל על הבית או שבדעתו להחיל על הבית מבטל או משנה הוראה של התקנון המצוי המתייחסת לענין מן העניינים המנויים להלן, חייב לכלול במפרט או לצרף לחוזה המכר פרטים על אותו ענין; ואלה העניינים:

- (1) הוצאת חלק מהרכוש המשותף;
 - (2) שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה;
 - (3) שיעור ההשתתפות בהוצאות הבית המשותף ובשירותים המחויבים בקשר אליו;
 - (4) סדרי קבלת החלטות בדבר ניהול הבית המשותף;
 - (5) כל ענין אחר שקבע שר השיכון בצו בדרך האמורה בסעיף 3(א).
- (ב) מוכר שלא מסר פרטים על ענין מהעניינים המנויים בסעיף קטן (א) יראוהו, על אף האמור בחוזה המכר, כמי שהתחייב שהוראות התקנון המצוי לגבי אותו ענין יחולו על הבית המשותף."

28. יפות לעניין זה, קביעות בית המשפט בע"א (ירושלים) [238/83](#) נציגות הבית המשותף נ' פנחס וחייה מרכוס (מא(2) 561 (1986):

"לעומת זאת, להתחייבות, לפי [סעיף 6\(א\)\(3\)](#), לשנות משיעור ההשתתפות בהוצאות, יהיה תוקף מחייב, ובלבד שתענה על דרישות הסעיף הנ"ל. הדרישות הן, כי כל שינוי מתוכנן התקנון



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 12/41/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- המצוי בעניינים המפורטים בו ייעשה באחת משתי הדרכים: על-ידי הכללתו במיפרט או על-ידי צירוף פרטים בנדון לחוזה. המיפרט הוא זה שמדובר בו בסעיפים 2(א) ו-3 של חוק המכר (דירות). הוראת סעיף 6 באה להבטיח, שקוני דירה יידעו בבירור, אם הוצאו חלקים מהרכוש המשותף על-ידי הצמדתם לדירות אחרות או אם נעשה שינוי אחר מהתקנון המצוי בעניינים שאותו סעיף חל עליהם. "קביעה זו אומתה גם ב עשא (ת"א) 50204-10-19 מגדל טופ - נדל"ן בע"מ נ' נציגות הבית המשותף (1.3.2020) (להלן: עניין מגדל טופ).
29. בדומה, בע"א (מחוזי ת"א) 6545-03-13 נציגות הבית המשותף "לב העיר" נ' אוניל בניה בע"מ (21.09.2014), נקודת המוצא לדיון בפני בית המשפט המחוזי, הייתה שניתן להתנות על הוראות סעיף 58 במסגרת הסכמי המכר של הקבלן. יצוין כי ערעור על פסק דין זה נדחה על ידי בית המשפט העליון ברע"א 7494/14 נציגות הבית המשותף "לב העיר" נ' אוניל בניה בע"מ (21.12.2014, להלן: עניין לב העיר).
30. מהאמור עולה כי ככל שההוראה בדבר שינוי שיעור הנשיאה בהוצאות הרכוש המשותף נקבעה במסגרת כלל הסכמי המכר אשר נכרתו בין טופ נדל"ן לבין הדיירים, הרי שיש לראות בה הוראה תקנונית המתנה כדין על הוראות סעיף 58 לחוק המקרקעין. וראו ענין מגדל טופ.
31. לפיכך, יש לדחות את הטענה כי לא ניתן להתנות בהסכמי המכר שנערכו בין הנתבעת לרוכשי הדירות על הוראות סעיף 58 לחוק המקרקעין. כמו כן, בבחינת מקל וחומר, יש לדחות את הטענה כי תנית פטור, מהסוג שנכלל בהסכמי המכר, מהווה הפרה של הוראות סעיף 30 לחוק החוזים בהיותה נוגדת את תקנת הציבור.

למפקח סמכות נגדרת לדון בשאלה האם תנאי בהסכם רכישה מהווה תנאי מקפח בחוזה אחיד

32. הנתבעת טענה כי אין למפקח על רישום מקרקעין סמכות לדון בשאלה האם תנית הפטור בחוזי הרכישה הם תנאי מקפח בחוזה אחיד. יש לדחות טענה זו.
33. ברי כי לצורך הכרעה בשאלה האם זכאית הנתבעת לפטור מתשלום דמי ניהול ואחזקה בהתאם לתנית פטור בהסכמי הרכישה, יש להידרש למחלוקת שבין הצדדים בשאלה האם יש לראות בתנית הפטור כ"תנאי מקפח בחוזה אחיד". הכרעה בשאלה זו מצויה בסמכותו של המפקח על רישום מקרקעין נוכח הוראת סעיף 76 לחוק בתי המשפט {נוסח משולב}, תשמ"ד - 1984 הקובעת כי "הובא העניין כדין לפני בית משפט והתעוררה בו דרך אגב שאלה שהכרעתה דרושה לבירור העניין, רשאי בית המשפט להכריע בה לצורך אותו עניין אם העניין שבשאלה הוא בסמכותו הייחודית של בית משפט אחר, או של בית דין אחר".
34. כפי שנקבע ברע"א 587/83, ועד הבית ברחוב תנועת המרי 2, קרית אונו נ' ירדני, (פ"ד לח) 4(4), 487 (1984) התייחס בית המשפט לפרשנותו של סעיף 76 לחוק בתי המשפט הנ"ל, בקובעו כדלקמן: "1. השאלה הראשונה, המתעוררת בערעור זה היא: האם הוסמך המפקח לדון בטענת המשיבים, ששטח המריבה שייך להם מכוח הסכם הרכישה שנחתם ביניהם לבין



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 12/41/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

החברה הקבלנית? המפקח הנכבד סבר שבסוגיית *lis aliubi pendens* עסקינן, שבגדרה מן הראוי הוא, שההליכים לפניו יעוכבו, ולא היא, שהרי התביעה לסילוק היד לחוד והתובענה הקניינית שהוגשה לבית המשפט המחוזי לחוד, ונושא התובענה בשני ההליכים אינו זהה: **ע"א 564/61**. 2. השאלה השנייה: האם הוסמך המפקח לדון כעניין שבגררא, בגדר תובעת סילוק היד שהוגשה לפניו, בזכויותיהם "הקנייניות" של המשיבים? לדידי אין הדבר מוטל בספק; כך הוחלט כבר לעניין הפקיד המוסמך לפי חוק בתים משותפים {נוסח משולב}, קודמו של המפקח, שהמחוקק לא הקנה לו, כמו למפקח, סמכויות של בית משפט שלום: **ע"א 191/66**, והוא - כדי למנוע תוצאה, שעל פיה "יבצר מהפקיד המוסמך לעשות את המלאכה שהחוק הטיל עליו (ראה דעת הרוב, מפי השופט זוסמן ז"ל, כתוארו אז, שם, בע"מ 510); קל וחומר הוא במפקח, שהוא "בית דין" למהדרין: **ע"א 44/72**, שסמכויותיו הן כסמכויות בית משפט השלום, כפי שמוסמך המפקח ליתן צו הריסה, כמו בית משפט שלום בגדר סעיף 75 לחוק **בתי המשפט** {נוסח משולב} (מקודם סעיף 34 לחוק בתי המשפט, תשי"ז – 1957): **ע"א 768/80**, כך רשאי הינהו לצורך העניין שלפניו, לדון בגררא בשאלה, שהכרעתה דרושה לביורר העניין, אף אם העניין שבשאלה הוא בסמכותו הייחודית של בית המשפט המחוזי...; וכבר נפסק, שלא ברשות שביסקול דעת עסקינן אלא בסמכות חובה: 89/63. והשווה 510/82". (ראו גם **ע"א 10112/03**, פת נ' קטלן – אסן (נבו 4.10.09); עשא (חי') 20-03-24779 עמית נ' נגר (נבו, 2.08.2020)).

הדברים ברורים, מדברים בעד עצמם, ויפים לענייננו.

תנית הפטור אינה תנאי מקפח בחוזה אחיד

35. חוק החוזים האחדים מגדיר חוזה אחיד כך:

"חוזה אחיד" – נוסח של חוזה שתנאיו, כולם או מקצתם, נקבעו מראש בידי צד אחד כדי שישמשו תנאים לחוזים רבים בינו לבין אנשים בלתי מסויימים במספרם או בזהותם;

כן קובע החוק מהו תנאי מקפח בחוזה אחיד ומה נפקות הקביעה כי תנאי בחוזה הוא תנאי מקפח:

תנאי מקפח וביטולו

3. בית משפט ובית הדין יבטלו או ישנו, בהתאם להוראות חוק זה, תנאי בחוזה אחיד שיש בו – בשים לב למכלול תנאי החוזה ולנסיבות אחרות – משום קיפוח לקוחות או משום יתרון בלתי הוגן של הספק העלול להביא לידי קיפוח לקוחות (להלן – תנאי מקפח).

ואילו סעיף 4 לחוק קובע מספר חזקות אשר בהתקיים אחת מהם קמה חזקה כי תנאי בחוזה אחיד הוא תנאי מקפח. התובעות מבקשות להסתמך על סעיף 4(1):



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 12/41/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

חזקות

4. חזקה על התנאים הבאים שהם מקפחים:

(1) תנאי הפוטר את הספק, באופן מלא או חלקי, מאחריות שהיתה מוטלת עליו על פי דין אילולא אותו תנאי, או המסייג באופן בלתי סביר את האחריות שהיתה מוטלת עליו מכוח החוזה אילולא אותו תנאי;

36. בעניין לב העיר נקבע כך: "למעלה מן הצורך, אני מבקשת להבהיר כי אכן לא כל שינוי שנעשה בנוסחו של חוזה "מאסטר" במשא ומתן בין הצדדים ימנע הכרה בחוזה שנחתם כחוזה אחיד (ראו: רע"א 8135/12 Nantucket Ltd נ' דורון, [פורסם בנבו] פסקה 26 (28.10.2013); ורדה לוסטהוויז וטנה שפניץ חוזים אחידים 28 (1994) (להלן: לוסטהוויז ושפניץ)). זאת ועוד, אין ספק שהכנסת שינויים בחלק מן החוזה אינה מונעת את החלת כלליו של חוק החוזים האחידים על חלק אחר בו שלא הוכנסו בו שינויים (לוסטהוויז ושפניץ, בעמ' 31; אריאל פורת "חוזים אחידים" 746, 729 חוזים כרך ג (דניאל פרידמן ונילי כהן עורכים, 2003)). כן חשוב להבהיר שבית משפט זה כבר עמד על החשיבות הנובעת לביקורת תנאיו של חוזה ניהול או חוזה שירותים בפרויקט מגורים, ובכלל זה תניות שעניינן תשלומים במסגרת חוזה ניהול (ראו והשוו: ע"א 449/85 היועץ המשפטי לממשלה נ' גד חברה לבניין בע"מ, פ"ד מג(1) 183, 193-192 (1989)). אולם, בכל מקרה ומקרה יש לבחון מהם השינויים שהוכנסו בחוזה האחיד ולהכריע בהתאם להם."

37. כאמור, באותו עניין נדחתה בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו מיום בע"א 6545-03-13 אשר במסגרתו קבע ביהמ"ש הנכבד כי על אף ש"שלד החוזה" הוא חוזה שתנאיו נקבעו מראש על ידי המשיבה, הסכם המכר שהוצג לדוגמה בבית המשפט כלל שינויים רבים בנספח שינויים שצורף לחוזה, ואף הושגה בו הנחה משמעותית ביחס למחיר הדירה. הוא הוסיף והדגיש כי בנספח להסכם זה נכתב שהוא חלק בלתי נפרד ממנו. בית המשפט המחוזי קבע שהוכח כי גם דיירים נוספים ניהלו משא ומתן ואף הכניסו שינויים בהסכמי המכר, לרבות בסעיף שעליו נסבה המחלוקת, ביחס לשלב שממנו ואילך תהא פטורה המשיבה בדמי הניהול, כך שבחלק מהחוזים נקבע כי הפטור מתשלום יחול רק לאחר שנחצה הרף של מסירת 90% מן הדירות. למעלה מן הצורך קבע בית המשפט המחוזי כי מכל מקום לא נראה שיש לראות בסעיף הנדון משום תנאי מקפח, וזאת נוכח העובדה שלצדו הושגה גם הנחה משמעותית במחיר הדירה, וכן בהתחשב בכך שעל אף העובדה שהסעיף לא הוגבל בזמן, בפועל השימוש בו מסתיים עם מסירת הדירות שבבעלות המשיבה, אשר נמכרו כמעט כולן.

38. לו היתה הנתבעת מבקשת להסתמך אך ורק על נוסח הסכמי המכר בינה לבין הרוכשים, אשר 9 מהם צורפו לכתב ההגנה המקורי, לא היה ספק כי מדובר "בחוזה אחיד" כמשמעותו בחוק. אולם, במסגרת כתב ההגנה המתוקן צירפה התובעת העתקים של 16 הסכמים של רוכשי דירות שונים שכותרתם "נספח שינויים להסכם". עיון בנספחי השינויים מלמד כי לא מדובר בנספח טכני המעלה על הכתב את מיקומה המדויק של הדירה הנרכשת, גודלה, מחירה וכיו"ב ונוקב



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 12/41/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- רק בשינויים טכניים או מינוריים בהסכם העיקרי. לפי נוסח נספחי השינויים השונים ניכר כי מרבית רוכשי הדירות החתומים עליהם נועצו בעורך דין טרם גיבשו עם הנתבעת את נוסח הסכם השינויים (אף אם הנספח לא נחתם ע"י עו"ד מטעמם). עיון בנספחים השונים מעלה כי רוכשי הדירות לא החסירו אף סעיף במבוא להסכם העיקרי ולא החמיצו אף סעיף בהסכם גופו טרם גובש נספח השינויים עמם ואין סעיף שלא ניתן היה לדון בו. כל הנספחים כוללים שינויים ותיקונים המתייחסים לעשרות סעיפים שונים בהסכם. ברי כי לכל אחד מרוכשי הדירות ניתנה אפשרות לעיין בנוסח ההסכם שהוא אמנם הסכם אחיד, להתייעץ עם כל גורם מקצועי שימצא לנכון ולבקש להכניס שינויים ותיקונים בכל אחד מסעיפי ההסכם. נספחי השינויים מעידים כי כל אחד מהרוכשים הרלבנטיים שם דגש אחר ביחס לתיקונים שרצה לבצע בהסכם המקורי.
39. ספק בעיני אם אכן ניתן להביט על כלל חוזי המכר שנערכו ונחתמו בין הנתבעת לרוכשי הדירות כחוזה אחיד. למען הזהירות אניח כי אכן מדובר בחוזה אחיד שחלות עליו הוראות סעיף 4 לחוק החוזים האחידים. או אז יש לבחון האם חלה על תנית הפטור החזקה הקבועה בסעיף 4 לחוק וכי היא מהווה תנאי מקפח בחוזה אחיד.
40. מקובלת עלי טענת התובעות כי אלמלא סעיף הפטור היה מוטל על הנתבעת לשלם את דמי הניהול בגין הדירות שנשארו בבעלותה ותנאי זה מקפח את רוכשי הדירות הנאלצים לשאת בנטל מוגבר לשם תחזוקת הרכוש המשותף. כאמור, חובתה של הנתבעת לשלם את דמי הניהול מעוגנת בסעיף 58 לחוק המקרקעין ואלמלא עוגנה בכל הסכמי הרכישה, או בתקנון מוסכם, לא יכולה היתה הנתבעת לטעון כי היא פטורה מתשלומם. על כן אני סבור כי חלה החזקה הקבועה בסעיף 4(1) לחוק החוזים.
41. אולם, לאחר שבחנתי את תוכן תנית הפטור, מחד גיסא, את "נספחי השינויים להסכם" ואת הנסיבות הרלבנטיות בעת הגשת התביעה, הגעתי לכלל מסקנה כי עלה בידי הנתבעת לסתור את החזקה שחלה על תנית הפטור ולהראות כי, בנסיבות העניין, היא אינה מהווה תנאי מקפח. יחד עם זאת אני סבור כי יש לסייג, או לחדד, את תחולת תנית הפטור ממנה זכאית הנתבעת ליהנות כך שתחול רק על דירות העומדות ריקות ולא על דירות שהשכירה לצד שלישי, או כאלו שהפכה למשרד לשימושה העצמי.
42. למסקנה זו הגעתי נוכח השינויים הרבים שהוכנסו בהסכם המקורי ע"י מספר לא מבוטל של רוכשי דירות, במסגרת נספחי שינויים להסכם, כפי שפורט לעיל. מקובלת עלי טענת הנתבעת כי תנית הפטור שבמחלוקת טומנת בחובה תמורה כלכלית הניתנת באופן יחסי ע"י כל אחד מבעלי הדירות לנתבעת בכך שהיא עשויה להגדיל את דמי הניהול והתחזוקה שיידרש לשלם לאחר מסירת הדירה לידיה ותחילת גביית דמי ניהול ועד הנתבעת תמכור את כל הדירות שבנתה. בחינת התמורה הכלכלית המגולמת בתניה זו צריכה להיעשות בהיבט הכולל של התמורות שכל צד מקבל בהתאם להסכם המכר. אני סבור כי לכל אחד מהרוכשים היתה אפשרות אמיתית לבחון ולמדוד את ה"מחיר" הכלכלי של תנית הפטור בו הוא יישא ולבקש



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 12/41/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

תמורה נגדית כנגדו, כגון הנחה במחיר הדירה, או במחיר הכרוך בהצמדה של חניה או מחסן; הקלה באפשרות לבטל את ההסכם – כפי שנעשה בנספח עם בני הזוג אבוביץ; הרוכש יכול לבקש שדרוג של אחד מסעיפי המפרט של הדירה שהוא רוכש כגון בריצוף או במטבח וכד' – כפי שנעשה בכל נספחי השינויים שהוגשו; הרוכש גם יכול לעגן את עלות רישום דירתו בעת רישום הבית המשותף – כפי שעשתה משפחת אוזנה; הרוכש יכול לבקש פרישה רחבה יותר של התשלומים או הארכת המועד להשבת ערבות המכר לידי הנתבעת – כפי שביקשו בני הזוג איידלין ובני הזוג שוורצמן; הרוכש יכול להקטין את פרק הזמן בו עיכוב במסירה יחייב פיצוי מאת הנתבעת. עובדה היא כי הרוכשים עזריאל ביקשו להכניס בהסכם התייחסות לגובה דמי הניהול כך ש"דמי הניהול יהיו בסכומים סבירים ומקובלים בפרויקט מסוג זה" וחזקה כי הבינו שקלו את עלות הפטור שיוענק לנתבעת; הרוכש הפוטנציאלי יכול היה להדרש לשיעור ההוצאות משפטיות – כפי שדרשו בני הזוג בורשטיין, אשר בנוסף, עמדו על כך שהנתבעת תתחייב שלא להציב אנטנה סלולארית על גג הבניין.

43. כפי שצוין בפסק דינו של ביהמ"ש המחוזי בעניין לב העיר לתנית הפטור ומכוחה גם לעלות הכלכלית הנוספת על כתפי רוכשי הדירות יש מועד תפוגה: המועד בו תמכור הנתבעת את כל דירותיה. ברי כי האינטרס של הנתבעת למכור את מלאי הדירות שברשותה בהקדם האפשרי עולה בשיעור ניכר על "הרווח" שהיא מקבלת מהיותה פטורה מתשלום דמי האחזקה והניהול עבור הדירות הלא מכורות, העומד ע"ס של 1,500 ₪ מדי חודש. יש לזכור כי עסקינן בפרויקט מגורים אשר תוך כדי הקמתו ואכלוסו מבקש היזם למכור את כל מלאי הדירות שהוא בונה, זאת בשונה מהמצב הדברים שעשוי להיות כאשר מוקם פרויקט מסחרי ובו היזם, לעתים קרובות, ממשיך להיות הבעלים של יחידות רבות זמן רב לאחר אכלוס המבנה, אותן הוא משכיר.

44. בכתב ההגנה המקורי נטען כי הנתבע מכרה עובר לחודש מאי 2020 מעל 70% מהדירות בפרויקט, דהיינו נשארו בבעלותה פחות מ-56 דירות. בכתב התביעה המתוקן נטען כי בבעלות הנתבעת 30 דירות. נתון זה אומת למעשה בתצהיר מטעם שהוגש מטעם הנתבעת ונחתם ביום 30.5.21 ולפיו נותרו בבעלותה 30 דירות בבית המשותף. עולה אם כן כי גם מאז הגשת התביעה המשיכה הנתבעת למכור דירות שהיו בבעלותה וניתן להניח כי דירות נוספות נמכרו מאז הגשת התצהיר האמור. נתונים אלו מחזקים את ההנחה כי לנתבעת אינטרס כלכלי שלא להחזיק דירות ריקות חרף הפטור מדמי החזקה וניהול החלים עליהן, וכן כי שווי היקף הפטור המוענק לנתבעת הולך וקטן בחלוף הזמן וצפוי להתאפס.

45. עוד אני סבור כי תנית הפטור עליה מבקשת להסתמך הנתבעת לא מהווה תנאי חריג במסגרת הסכמי רכישה של פרויקט מגורים ועומד מאחוריה הגיון כלכלי שחל גם במישור של ניהול ותחזוקת הבית המשותף לאחר אכלוסו. ברי כי העומס על מתקני הבית המשותף, אשר בפרויקט בו עסקינן הנם מורכבים ויקרים, קטן יותר כאשר דירות רבות אינן מאוכלסות. מטבע הדברים, כאשר דירת מגורים שעמדה ריקה עת הושלמה הבנייה וכעת מאוכלסת מגדילה את



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 12/41/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

השימוש במעליות, בלובי, בחדר הדיירים, בחניון הבית המשותף, בחדר האשפה, בתאורה וכיוב'. הפטור שהנתבעת ויזמים רבים מבקשים לקבל מתשלום דמי החזקה וניהול עבור דירות ריקות בעל הגיון כלכלי מוצק. תנית הפטור דן אף מביאה בחשבון את הצורך להימנע מכך שבשלבי האכלוס המוקדמים מתן פטור לכל הדירות הריקות שבבעלות היזם יביא למצב בו מעט בעלי דירות נדרשים לשאת בנטל התחזוקה של הרכוש המשותף ועל כן נקבע בתנית הפטור כי כל עוד לא נמכרו 60% מהדירות תשא הנתבעת ב 50% מדמי הניהול והתחזוקה של הדירות שבבעלותה. עובדה היא כי הנציגות, או מי מבעלי הדירות, לא סברו כי בתקופה בה החזיקה הנתבעת בלמעלה מ 60% מהדירות היה מקום לחייב אותה בתשלום כל דמי הניהול ולהורות על ביטול תנית הפטור. לא הובהר מדוע מקובלת על הרוכשים הרישא של תנית הפטור, לפיה פטורה היתה הנתבעת מתשלום מחצית דמי ניהול מרגע אכלוס הבית המשותף ולמשך תקופה ארוכה, אך מסרבים לקבל את הסיפא של תנית הפטור המעניקה לנתבעת פטור מלא מחודש מאי 2020 (אין לפני נתונים בדבר הפטור שניתן לנתבעת טרם כניסת שמדר לפעילות ומתי נחצה רף המכירות של 60%).

46. דומה כי גם התובעות מכירות בהגיון הכלכלי העומד מאחורי תנית הפטור ועל כן טענו כבר בראשית סיכומיהם כי בידיהן ראיות לכך כי הנתבעת משכירה חלק מהדירות שבבעלותה וגובה מהשוכרים דמי ניהול אותם היא משלשלת לכיסה.

47. אכן, כנגד הנימוקים המצדדים בהגיון של מתן פטור לדירות ריקות שבבעלות הנתבעת, הן במישור המסחרי והן במישור של ניהול הבית המשותף, עומד הנימוק הנגדי התומך בחיוב הנתבעת בתשלום דמי הניהול עבור דירות אותן בחרה להשכיר ולא למכור. כן אציין כי אני סבור כי ככל שהנתבעת גובה דמי ניהול משוכרים בדירות בבית המשותף דן הרי שאי-העברת דמי הניהול לידי התובעות מקימה להן, לכאורה, עילה מכח דיני עשיית עושר ולא במשפט, זאת גם אם אשר את תנית הפטור כלשונה.

אני סבור כי אכן אין מקום להחיל את תנית הפטור על דירות שמושכרות ע"י הנתבעת לצד שלישי (זאת אף אם אינה גובה דמי ניהול מהשוכרים שלה) או על דירה, ככל שיש כזו, שהסבה הנתבעת למשרד המשמש אותה לצרכיה.

48. נוכח כל האמור לעיל הנני לקבוע כי הסעיף בחוזי המכר, הפוטר את הנתבעת מתשלום דמי אחזקה וניהול מהמועד בו מכרה 60% מהדירות שבנתה בבית המשותף, אינו מהווה תנאי מקפח בחוזה אחיד ואין מקום לפסול אותו, זאת בכפוף לכך שהסעיף לא יחול על דירות שהנתבעת השכירה לצד ג' או על דירה שהסבה הנתבעת לשימוש משרדי על ידה.

49. לצורך המשך בירור התביעה התובעות יודיעו תוך 14 יום אם, נוכח גילוי המסמכים שנעשה עד כה, הן חולקות על טענת הנתבעת כי בחודש מאי 2020 כבר מכרה מעל 60% מהדירות.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 12/41/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בד בבד הנתבעת תגיש תוך 14 יום הודעה האם מאז חודש מאי 2020 עד היום השכירה דירות שבבעלותה (או הסבה אותן למשרדים שבשימושה) ואם כן תגיש טבלה המפרטת את מס' הדירה ומועד תחילת השכרתה.
50. הוראות בדבר המשך בירור ההליך יינתנו בהתאם לתוכן ההודעות שתוגשנה.

ניתן ביום 17 פברואר 2022, ט"ו אדר א' תשפ"ב, בהעדר.

אלעד אזר
מפקח על רישום מקרקעין